

## <입문-제3장 행정법의 일반 원칙.제1절 비례의 원칙>

### I. 개설

#### 1. 개념

- 비례의 원칙은 행정주체가 행정목적 달성을 위하여 행정작용을 할 때, 그 목적과 수단 사이에 합리적인 비례 관계가 있어야 하며, 특히 국민의 권리를 제한하거나 침해하는 경우 필요 최소한의 정도에 그쳐야 한다는 행정법의 일반 원칙 중 하나다. 이는 과잉금지의 원칙이라고도 불리며, 공익과 사익의 조화를 목적으로 한다. 법치국가 원리의 실질적 실현을 위한 중요한 통제 수단으로 기능한다.

#### 2. 법적 근거

##### (1) 헌법적 근거

- 비례의 원칙은 명문화된 규정은 없지만, 헌법이 보장하는 국민의 기본권을 국가 권력으로부터 보호하려는 헌법 제37조 제2항의 기본권 제한의 한계 원칙에 일반적 근거를 두고 있다. 헌법 제37조 제2항은 국민의 자유와 권리는 국가 안전 보장, 질서 유지 또는 공공 복리를 위하여 법률로써 제한할 수 있으나, 제한하는 경우에도 자유와 권리의 본질적인 내용을 침해할 수 없다고 규정한다. 비례의 원칙은 이러한 기본권 제한에 대한 최소한의 기준을 제시한다.

##### (2) 개별 법률적 근거

- 행정기본법 제10조는 행정목적 달성을 데 유효하고 적절할 것, 행정목적 달성을 데 필요한 최소한도에 그칠 것, 행정작용으로 인한 국민의 이익 침해가 그 행정작용이 의도하는 공익보다 크지 아니할 것라고 하여, 행정작용에 대한 비례의 원칙을 명시적으로 규정한다. 이로써 비례의 원칙의 세 가지 요소(적합성, 필요성, 상당성)를 법정화하고 있다.

#### 3. 적용 범위

##### (1) 행정작용 전반

- 비례의 원칙은 행정주체가 수행하는 모든 행정작용에 일반적으로 적용되는 불문 법원이다. 침익적 행정(제재 처분, 의무 부과 등)은 물론, 수익적 행정(특허, 허가 등), 행정입법을 포함하는 광범위한 영역에 걸쳐 적용된다.

##### (2) 침익적 행정작용의 통제

- 비례의 원칙은 특히 국민의 권익을 제한하는 행정 처분에 대한 사법적 통제의 핵심 기준으로 활용된다. 예를 들어, 위반 행위에 대한 제재 처분(영업 정지, 과징금 부과)의 종류나 정도가 위반 행위의 중대성에 비하여 지나치게 가혹한 경우, 비례의 원칙 위반으로 위법성이 인정될 수 있다.

##### (3) 재량 행위의 통제

- 법률이 행정청에 재량권을 부여한 경우에도, 비례의 원칙은 재량권 행사의 한계를 설정하는 기준이 된다. 행정청이 재량을 행사할 때 비례의 원칙을 위반하면 이는 재량권의 일탈 또는 남용에 해당하여 위법하게 된다.

### II 비례원칙의 내용

#### 1. 비례원칙의 구성

- 비례의 원칙은 세 가지 하위 원칙으로 구성되어 있으며, 이들은 단계적으로 행정작용의 적법성을 심사하는 기준이 된다.

##### (1) 적합성의 원칙

- 행정주체가 행정목적 달성을 위해 선택한 수단이 그 목적을 달성하는 데 실질적으로 기여할 수 있어야 한다는 원칙이다. 만약 선택된 수단이 목적 달성에 전혀 도움이 되지 않거나 비합리적이라면, 그 행정작용은 부적합하여 위법하게 된다. 이는 행정작용의 효율성을 요구하는 측면이 있다.

##### (2) 필요성의 원칙

- 행정목적 달성을 데 적합한 여러 수단 중에서 국민의 권리를 가장 적게 침해하는 최소한의 수단을 선택해야 한다는 원칙이다. 이를 최소 침해의 원칙이라고도 한다. 행정청은 동일한 목적을 달성할 수 있는 여러 가지 수단이 있을 경우, 국민에게 가장 덜 부담이 되는 수단을 우선적으로 사용해야 한다.

##### (3) 상당성의 원칙(협의의 비례의 원칙)

- 선택된 수단으로 인해 국민이 침해받는 사익(私益)과 그 행정작용을 통해 달성하고자 하는 공익(公益) 사이에 합리적인 균형이 이루어져야 한다는 원칙이다. 즉, 침해되는 사익이 달성되는 공익보다 현저하게 크지 않아야 한다. 만약 사익의 침해가 공익보다 지나치게 큰 경우, 이는 과잉 금지에 해당하여 위법하게 된다. 판례는 이 원칙을 엄격하게 적용하여 제재 처분의 가혹성 여부를 판단한다.

#### 2. 단계적 구조

- 비례의 원칙에 따른 심사는 적합성, 필요성, 상당성의 순서로 단계적으로 이루어진다. 선행 단계의 원칙을 충족하지 못하면 후행 단계의 심사로 넘어갈 필요 없이 위법이 인정된다.

##### (1) 제1단계 : 적합성 심사

- 행정작용이 정당한 행정목적 달성을 데 효과적인지 여부를 심사한다. 예를 들어 무허가 건물에 대한 강제 철거 명령은 도시 계획이라는 행정 목적 달성에 적합한 수단이다.

##### (2) 제2단계 : 필요성 심사

- 적합성이 인정된 수단 중에서 국민에게 가장 덜 부담을 주는 대안적인 수단이 있는지 여부를 심사한다. 예를 들어 강제 철거 대신 사용 중지 명령이나 벌금 부과 등 덜 침익적인 수단이 있는지 검토한다. 행정청은 최소 침해 수단을 선택해야 한다.

##### (3) 제3단계 : 상당성 심사

- 최소 침해 수단이 선택되었다 하더라도, 그 수단으로 인해 침해되는 사익과 달성되는 공익을 비교 형량하여 침해의 정도가 균형을 이루는지 심사한다. 예를 들어 경미한 위반에 대해 영구적인 영업 허가 취소를 하는 것은 공익에 비해 사익 침해가 과도하여 위법하다.

### III 위반의 효과

#### 1. 행정작용의 위법성

- 행정주체가 비례의 원칙을 위반하여 행한 행정작용은 위법하게 된다. 위법성의 정도에 따라 무효 또는 취소의 원인이 된다.

##### (1) 취소 사유

- 비례의 원칙 위반이 중대·명백하지 않은 경우(중대 OR 명백)에는 취소할 수 있는 행위로 본다. 대부분의 경우 제재 처분의 양정 과다는 재량권의 일탈 또는 남용으로 간주되어 취소소송의 대상이 된다. 판례는 영업 정지 기간이 위반 행위의 경중에 비해 지나치게 가혹한 경우 위법하여 취소되어야 한다고 본다.

##### (2) 무효 사유

- 비례의 원칙 위반이 중대·명백한 경우(중대 AND 명백)에는 무효 사유가 될 수 있다. 예를 들어, 처분의 목적 자체가 행정목적과 무관하며 사익만을 침해할 목적인 경우 등이다.

## **2. 국가 배상 책임**

- 행정주체가 비례의 원칙을 위반하여 위법한 행정작용을 함으로써 국민에게 손해를 입힌 경우, 이는 공무원의 직무상 불법 행위에 해당하여 국가배상법에 따른 손해 배상 책임이 발생할 수 있다.

## **3. 재량권의 한계 설정**

- 비례의 원칙 위반은 재량 행위에 있어서 재량권의 한계를 일탈하거나 남용한 것으로 간주되어 사법 심사를 통해 위법성이 확인된다. 이는 행정청의 자의적인 권한 행사를 방지하고 국민의 권익을 실질적으로 보호하는 가장 중요한 역할을 한다.

## **IV. 결론**

- 비례의 원칙은 법치국가 원리와 기본권 보장을 실질적으로 구현하는 핵심 원칙으로서, 행정주체의 모든 행정작용을 적합성, 필요성, 상당성의 단계적 구조를 통해 통제한다. 행정작용이 행정목적 달성에 적합해야 하고, 최소한의 침해 수단이어야 하며, 공익과 사익 간에 균형을 이루어야 한다는 이 원칙은, 특히 국민의 권리를 제한하는 침익적 행위와 행정청의 재량권 행사에 대한 사법 통제의 가장 강력한 기준이 된다. 비례의 원칙을 위반한 행정작용은 중대하거나 명백한 경우는 취소, 중대하고 명백한 경우는 무효의 대상이 된다.